“《民法典》中的土地制度解读”笔谈

左传卫　宋宗宇　陈洁斌　宋志红　黄　忠　单平基　姜红利*

主持人（刘云生教授）语：

《民法典》已于2021年1月1日正式实施，成为我国民法学研究由立法论转向解释论的重要转折点。《民法典》在编纂过程中吸收、固化了新一轮土地制度改革的成果，当前的重点任务是解读《民法典》中的土地制度，对相关条文的理解与适用进行学理分析。为此，本集刊组织了“《民法典》中的土地制度解读”笔谈，共有7位专家6篇短文参与本次笔谈。

左传卫在《论宅基地“三权分置”的困境原因与可能的化解之道》一文中认为，因宅基地的交易空间狭窄，宅基地“三权分置”并没有在广大农村产生相应的政策效果，要盘活闲置的宅基地与农房，需分析造成交易空间狭窄的特殊原因，寻求针对性的化解之道。在坚持集体土地公有制的前提下，可以通过扩张《民法典》居住权的内涵，以消费性、投资性居住权来盘活宅基地与农房。

宋宗宇、陈洁斌在《集体经营性建设用地入市收益分配的法律困境及对策分析》一文中认为，集体经营性建设用地入市收益分配存在上位法缺失、土地增值收益调节金法律性质不明，以及集体内部收益分配的限制规则不够明确的问题，应当稳步建立集体土地增值收益税收制度、通过法律明确政府职能以及预留与其他制度进行衔接的立法空间。

宋志红在《〈民法典〉视野下的集体建设用地使用权》一文中认为，《民法典》物权编第十二章“建设用地使用权”并未为集体建设用地使用权的运行规则提供直接的制度供给，《土地管理法》第63条关于集体建设用地使用权设立主体和方式的规定，需结合《民法典》的规定予以理解、补充和完善。

黄忠在《〈民法典〉用益物权分编的解释论三题》一文中认为，基于体系解释，用益物权人并不当然具有独立的征收补偿资格；基于历史解释，《民法典》中的变更登记是一个具有双重内涵的概念，包括“转移登记”“变更登记”两种情形；基于目的

* 左传卫，广州大学法学院副教授；宋宗宇，重庆大学法学院教授、博士生导师；陈洁斌，重庆大学法学院硕士研究生；宋志红，中央财经大学法学院教授；黄忠，西南政法大学民商法学院教授、重庆英才·名家名师首批人选；单平基，东南大学法学院副院长、副教授、博士生导师，东南大学民事检察研究基地主任；姜红利，南京师范大学法学院讲师、中国法治现代化研究院研究员。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（功能）解释，可以地役权、居住权来指引地票（用地指标）交易、宅基地“三权分置”的改革实践。

单平基在《〈民法典〉中土地制度适用应关注的几个问题》一文中认为，住宅建设用地使用权到期后，如何续期、续期费用的缴纳或减免等问题，尚需立法进一步明确。土地承包经营权已可作为融资担保的客体，不再限于以“荒地”承包经营权设定抵押，值得肯定。从功能主义看，土地经营权的融资担保形式，既可采取抵押，也应解释为可设定权利质押。

姜红利在《保留进城落户农民土地承包经营权的制度背景和价值》一文中认为，新型城镇化道路应逐渐转变户籍决定论的城镇化理念，这是正确解读进城落户农民可以保留土地承包经营权的制度背景。构建独立于退出机制的进城落户农民土地承包经营权保留制度具有合法合理性，是城乡互动融合的一种制度探索。

关键词：民法典；集体经营性建设用地；居住权；土地经营权；宅基地使用权

论宅基地“三权分置”的困境原因与可能的化解之道

左传卫

为解决大量农村宅基地闲置的问题，满足农村建设用地需求，2018年中央“一号文件”提出宅基地“三权分置”，为宅基地制度顶层设计奠定了基础。但从2018年初到2020年底的实际效果来看，宅基地“三权分置”似乎并未取得如农地“三权分置”那样的实效，其原因何在？

宅基地“三权分置”政策意在盘活农村闲置的宅基地和房屋，使农民获得相应的财产价值。其政策手段是在原来两权分置的基础上增加“资格权”。原来有关宅基地的权利组成是农民集体的宅基地所有权、农民的宅基地使用权，现变更为农民集体的宅基地所有权、农户的宅基地资格权和农民的宅基地使用权。这样的“三权分置”权利组合是否就能达到“完善农民闲置宅基地和闲置农房政策……落实宅基地集体所有权，保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权，适度放活宅基地和农民房屋使用权”的政策意图呢？

农户资格权究竟是什么，中央文件没有言明，现行法律体系中也没有这一特定概念。学者们对此认识不一，有的认为资格权就是社团成员权，犹如公司股东的身份权一样；有的认为农户资格权是用益物权，应定性为创设次级使用权后行使受到限制的宅基地使用权。[①] 应当说，虽然原来的两权分置没有资格权的表述，但实际上农户如果

① 参见刘国栋《论宅基地三权分置政策中农户资格权的法律表达》，《法律科学（西北政法大学学报）》2019年第1期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

想要取得宅基地，其必须是本集体经济组织的成员，这一资格是先在的前提，所以从法理上分析，“资格权”的提法并没有什么新意。

宅基地“三权分置”政策是在农地“三权分置”政策取得比较大成效的基础上推出来的，为什么农地“三权分置”能基本上达成政策预期，而宅基地“三权分置”却“理想丰满、现实骨感”呢？或许通过对比分析农地“三权分置”成功的原因，可以明晰宅基地“三权分置”困境的根源。

一　农地“三权分置”成功的原因

在20世纪80年代，农村土地承包经营制度因突破集体统一经营的僵化低效困境，曾焕发出勃勃生机，为我国市场经济改革奠定了基础，但至今其政策红利似乎已释放殆尽了。几十年来农村除了翻新更多房屋外，农地的经营模式与效率基本上原地不动，与整个国家的综合实力相比，农业发展较为落后。究其原因，农地承包经营虽然打破了集体经营的僵化低效，让农户的个体性、主动性脱颖而出，但单个农户豆腐干式的分割耕作使整个农业呈现分散的原子化状态，难以通过现代资本运作方式形成以规模化、企业化、高科技、资金密集为特征的现代农业。农地“三权分置”就是针对这个现状，将与农地相关的权利分解成农村集体的所有权、农户的承包经营权和农地经营权三种权利类型，试图让具有身份限制的农民土地承包经营权进入市场转化成没有人身依附性、纯粹的财产权——农地经营权，这是一种完全按市场要素模型来构建的新型权利，它可以让农户以自由意志根据自己对市场的判断自由地组合、转让、抵押、入股。这样，封闭经营的农业终于面向了广阔无垠的市场，这就是目前全国各地尤其是经济比较发达的东南沿海地区农业股份制经济迅速发展的原因。①

二　宅基地“三权分置”困境的原因

同样是盘活资产，同样都采取了“三权分置”方法，为何农地“三权分置”取得了较大成功，基本达成政策预期，而宅基地“三权分置”却基本不见成效，流于政策的自言自语呢？关键还是市场二字。宅基地“三权分置”与原来的两权分置相比并没有拓宽市场要素。在两权分置模式下，宅基地及宅基地上的房屋只能在本村集体经济组织范围内流转，排斥了外部交易主体的进入，而本村成员之间具有巨大的同质性，没有因互补而导致的交易需求，交易基本上无从发生。由于宅基地的福利性，只要是集体经济组织成员，每户都可以免费申请。根据《中华人民共和国土地管理法》第62条之规定，村民之间无论是买方还是卖方都没有流转闲置宅基地的利益驱动。而且，

① 参见孙宪忠《推进农地三权分置经营模式的立法研究》，《中国社会科学》2016年第7期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

由于农村盖房成本与城镇商品房相比，存在巨大的价格落差，村民一般都倾向于申请宅基地后自己盖房。宅基地“三权分置”在两权分置的基础上，试图增加一个成员权的权利类型，达到盘活农村资产的目的，自始就没有契合农村实情，无法从政策语言转变为农民生活语言。

宅基地“三权分置”改革因市场空间的狭窄而难以实现政策盘活农村资产的目标，那么，要盘活农村宅基地，就必须分析是什么原因导致了市场空间的狭窄，只有这样才能从根本上拓宽市场，活跃交易。

影响宅基地及农房的交易规模主要有以下两个原因：一是政治管理的原因。现行农村的基本格局是在20世纪50年代城乡二元割裂的政策下形成的。当时城乡二元格局的目的是以村民的身份限制农民的自由流动，将广大农村分割成一个个网格状行政细胞，在组织上每个村都是自然生成的封闭单元，外面的人口无从迁入，里面的人口只有通过几条通道（比如升学、转干等）可以转出。虽然我国市场经济改革已经推进了几十年，但这种因政治而形成的各个村落之间行政管理上的封闭状态至今依旧牢固。二是土地制度改革的原因。随着城市建设的日新月异，城镇土地的价格也随之攀升，各级地方政府通过土地变现获得了巨大的财政收入，并以此推动城镇基础建设。如果没有卖地收入，财政的扩张甚至维持能力都将大为萎缩。所以，维持城镇土地价格，排斥其他利益主体的竞争加入，就成为政策考量的一个重要因素。而维持城镇土地价格，最重要的就是限制土地供给，尤其是限制庞大的农村土地进入市场。如果不从根本上解决这两个问题，无论是两权分置、“三权分置”还是百权、千权分置，农民的土地权利都是处于限缩状态的，无法真正盘活资产。

三　宅基地及农房交易空间狭窄的再考量

破解宅基地“三权分置”的困境，其实就是对上述限制宅基地交易空间的两个原因的重新考量。首先，宅基地自由入市对行政管理的影响问题。只有大规模的人口自由流动，发挥各地的比较优势，广大农村才会真正变成理想中的社会主义新农村。可以预计，将来的行政管理必定会消解农村村民和城镇居民这种身份划分，统一以国民、居民称之。

其次，宅基地入市对城镇国有土地垄断价格的冲击问题。维持土地价格稳步增长，使地方土地财政收入持续增长，是我国最近几十年发展的重要因素。如果允许农村土地不经过国有征收环节直接入市，等于是让农民直接分享了各级地方政府土地开发的红利，这对于在城市建设上投入巨大人力物力的地方政府来说是不公平的，是一种直接的利益抢夺。农村土地入市，其上并没有附着先进的生产力，仅仅是一种原始的生

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

产要素，其不可能创造明显的财富效应、社会效应，仅仅是分享以城镇土地价格为代表的城市财富效应，是一种存量财富的分配，拉平了城市农村间的财富落差。如果允许农村宅基地及其上的房屋直接入市，会从根本上消解各级地方政府土地开发的动力。这应该是国家始终不允许宅基地及其上的房屋直接入市，不允许“小产权”房转正的背后根源之所在。

如果按照这样的逻辑分析，盘活农村闲置的宅基地及农房，本身就是一个伪命题。如果要破解，只有比较分析允许宅基地直接入市与土地财政这种发展模式的优劣，如果能证明土地财政模式并不必然优越于生产要素的全面自由流动，那么限制农村资产的自由交易就失去了逻辑上的正当性。

按照当下这种城市发展模式，城市开发到哪，土地就征收到哪，确保土地开发红利大部分归于开发者，只有当土地开发的边际效用到达临界点，甚至递减了，各级地方政府才不会限制农村宅基地直接入市。所以，要盘活农村资产就要分析现在城市开发的边际效用处在哪个位阶上。应该说，无论是国家宏观政策，还是实际社会运行，我国城镇化方兴未艾，城市开发的边际效用还远没到达临界点。所以，要盘活农村资产，就必须审视、检讨以土地财政为推手的城市开发模式的正当性，只有这样才可以为盘活农村宅基地寻求正当性。

土地财政这种发展模式是一种短期内高速见效的模式，但它的致命弱点也在于它的短期功利性。建立在城乡二元格局下优先发展城镇，让城镇辐射乡村这种人为的行政规划的合理性、科学性便值得怀疑反思，那么，将农村土地排除在自由市场经济之外是否还有必要，也便值得反思。

四　宅基地“三权分置”困境的可能化解之道

坚持土地公有制是土地制度改革的大前提，那么，可以考虑扩张《民法典》上居住权的内涵，使其越过福利性与人身依附性的藩篱，与市场经济相融合，利用其有偿性、投资性来化解宅基地“三权分置”的困境。

居住权虽然在其诞生时，以及在随后漫长的实践过程中，其制度定位是保护弱势群体的特殊需求，具有无偿性与人身依附性，[①] 但那是在农耕时代社会保障制度没有建立起来时所呈现的特色，并不意味着居住权的功能定位就必须限定在弱势群体的救济上。[②] 实际上，随着时代的变迁，居住权的功能越来越多样化。有学者统计，自 2005

① 参见汪洋《集体土地所有权的三重功能属性——基于罗马氏族与我国农村集体土地的比较分析》，《比较法研究》2014 年第 2 期。

② 参见鲁晓明《“居住权”之定位与规则设计》，《中国法学》2019 年第 3 期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

年1月1日截至2019年8月1日，与居住权有关的案例多达31740件，其中属于物权纠纷案件的共计12044件，其占比高达37.95%，超过了样本总数的1/3；而在婚姻家庭和继承领域发生的居住权案例共计9410件，占样本总数的29.65%。因此，婚姻家庭和继承领域并不是我国产生居住权纠纷的首要领域，更不是唯一领域，婚姻法和继承法上的居住权规范并不能“包打天下”。[①] 在现代市场经济大环境下，体现传统特色的、维护婚姻家庭稳定和社会公平正义的保障性居住权，与体现市场交换特色的、促进物尽其用和意思自治的投资与消费性居住权，完全可以和谐共存。而且比较而言，后者的发展空间更大。近些年涌现出各种名义的居住权，比如合作建房时设置的居住权、合资购房时设置的居住权、住房合作开发模式中的居住权、时权式酒店中的居住权、以房养老模式中的居住权、酒店式公寓与长租公寓中的居住权等，这些不同名称的投资与消费性居住权，都在不同程度上突破了传统人役权的限制，朝着用益物权的方向实现其功能嬗变。

具体到盘活宅基地及农房的运用上，可以将上述各种做法单独或者组合性地复制，让集体经济组织以外的各类社会主体涌入农村，让村民根据自己的意思自治自由判断如何与各类投资主体合作，从而最大限度地实现宅基地及农房的财产价值。

集体经营性建设用地入市收益分配的法律困境及对策分析*

宋宗宇　陈洁斌

2020年《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》要求制定农村集体经营性建设用地入市配套制度，而入市收益分配制度则是其中之一。本文拟就目前集体经营性建设用地入市收益分配中存在的法律问题进行梳理，就其原因进行剖析并提出法律建议。

一　集体经营性建设用地入市收益分配中存在的法律问题

（一）统一法律规定的缺失

2019年修正的《中华人民共和国土地管理法》（以下简称《土地管理法》）允许集体经营性建设用地入市交易，但未就收益分配进行规定。2020年5月28日，全国人大通过的《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）吸收了《土地管理法》

① 参见曾大鹏《居住权的司法困境、功能嬗变与立法重构》，《法学》2019年第12期。

* 本文是国家社会科学基金青年项目“农村集体非经营性资产运行法律机制研究”（20CFX039）的阶段性成果。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的内容，但未对集体建设用地使用权作更多规定。2020年3月30日公布的《中华人民共和国土地管理法实施条例（修订草案）》（以下简称《土地管理法实施条例（修订草案）》）仅在第39条提及收益分配，对具体规则亦未作更多规定。由财政部、原国土资源部印发的《农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金征收使用管理暂行办法》（以下简称《调节金暂行办法》）仅对土地增值收益调节金进行了规定，但地方实践的具体做法与《调节金暂行办法》在征收基数、比例以及用途等方面多有出入。[①] 因此，要进一步扩大入市规模，保障农民收益不受损，在法律层面上需要固定规则以保障各方权利。

（二）土地增值收益调节金的法律性质不明

集体经营性建设用地入市收益是指土地流转产生的收入和利益的总和。[②] 目前政府分享入市收益的方式是通过单独规定土地增值收益调节金这一制度参与分配，并且未将调节金的收入列入税收收入。原国土资源部印发的《关于促进农业稳定发展农民持续增收推动城乡统筹发展的若干意见》提出了“初次分配基于产权，二次分配政府参与”的政策要求。农民集体是集体土地的唯一主体，[③] 土地包括附着于土地上的一切财产利益，亦包括因土地开发和土地发展而产生的土地增值部分。[④] 政府不能直接参与收益的分配，但可以通过其他形式调节收益，进而达到社会公平的目的，例如税收。目前，国家拟规定集体土地使用权的增值税。财政部于2019年公布的《中华人民共和国土地增值税法（征求意见稿）》（以下简称《土地增值税法（征求意见稿）》）中规定集体土地使用权及其附着物转让等应当缴纳土地增值税，缴纳土地增值税可能会成为土地增值收益调节金的最终替换方案，但该草案尚未提请全国人大常委会审议。由于我国未能在法律层面上对参与收益分配的方式进行明确规定，导致了实践中对调节金相关规定的继续模糊化。

（三）集体内部收益分配的限制规则不明

根据《中华人民共和国立法法》第73条，地方性法规为执行行政法规的规定，可以结合根据本行政区域的实际情况作具体规定。在上位法对收益分配方法规定缺失的情形下，各地区的内部收益分配规则规定了对集体提留比例、提留用途的限制以及规定方案需要经政府审批。以集体收益为例，四川省成都市郫都区要求集体公积金提留不得低于80%，天津市蓟州区则规定提留资金只能用于村内基础设施、公益福利事业

① 参见何芳等《国家集体农民利益均衡分配：集体经营性建设用地入市调节金设定研究》，《农业经济问题》2019年第6期。

② 参见宋志红《集体经营性建设用地入市改革的三个难点》，《行政管理改革》2015年第5期。

③ 参见姜红利、宋宗宇《农民集体行使所有权的实践路径与主体定位》，《农业经济问题》2018年第1期。

④ 参见李忠夏《农村土地流转的合宪性分析》，《中国法学》2015年第4期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

支出；就政府审批而言，试点地区还规定了政府对收益分配方案的行政审批权。根据《中华人民共和国村民委员会组织法》第5条的规定，乡镇人民政府对村委会予以指导、支持和帮助，但不得干预村民自治范围内的事项；并且在第24条规定了对于集体经济收益所得的使用属于村民自治的事项范围。因此，集体收益的分配、用途应当属于村民自治的规定范围。在上位法未对集体内部收益分配进行规定或者授权规定的情形下，各地方对集体决议的土地收益分配方案进行规定，在一定程度上限制了村民自治。

二　关于收益分配的法律建议

（一）建立集体土地增值收益税制度

1. 土地增值收益调节金本质是政府税收

从目前规定看，土地增值收益调节金承担了税收的功能。从调节金的内容来看，一方面，调节金纳入政府预算收支分类中的“其他收入”并未直接否定其税收功能，仅是对调节金的财政管理的暂时规定；另一方面，契税也直接以调节金的方式收取，调节金是包含税收在内的政府应当收取的全部费用的总和。从调节金的具体属性来看，一是土地增值收益调节金由政府“征收”，具有强制性。二是农村集体经济组织作为特别法人，具有缴税的资格，而且入市具有营利性。三是政府通过收取费用以达到调节平衡的目的，具有公益性。因此，土地增值收益调节金具有强制性、营利性、公益性，具有税收的属性。[①] 笔者认为，在土地制度改革开始试点时，在未健全相关税收制度的情形下，将繁杂的土地税收统一规定为土地增值收益调节金有利于地方政府工作的开展。但是，具有强制性和无偿性的税收制度才是政府在集体土地增值收益分配中的最终归宿。

2. 集体经营性建设用地入市应当缴纳土地增值收益税

集体土地与国有土地“同等入市、同权同价”，集体土地也应当承担同样的法律义务与责任。要做到同等入市，即要和国有建设用地进入统一的交易平台，在同一个市场上按照同一套交易规则进行交易。[②] 在国有土地流转中用以调节土地收益、确保社会财富公平分配的方式即征收土地增值收益税。[③] 土地增值收益税与土地增值收益调节金存在相似性。第一，两者皆以土地增值收益为起征基数；第二，两者皆可以按照评估价进行征收；第三，两者征收比例相似，土地增值收益调节金的征收比例是20%~50%，而土地增值收益税的比例为30%~60%。

① 参见张守文《论税法上的“可税性”》，《法学家》2000年第5期。

② 参见韩松《论农村集体经营性建设用地使用权》，《苏州大学学报》（哲学社会科学版）2014年第3期。

③ 参见叶剑平等《中国土地增值税征收问题研究——背景、效果和建议》，《北京社会科学》2014年第5期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

根据《土地增值税法（征求意见稿）》的草案说明，我国将建立统一的土地增值收益分配机制，使税制与建立城乡统一建设用地市场的土地制度改革相衔接，同时，拟取消土地增值收益调节金，使立法前后集体房地产负担总体稳定。总而言之，集体经营性建设用地土地增值收益调节金应当通过立法转为土地增值收益税，以实现与国有土地真正的“同权同价”，建立统一的建设用地市场。

3. 土地增值收益税对保障农民利益的具体实现方式

要保障农民利益不受损，则要求在设计土地增值收益税制度时对农民利益进行保护，主要可通过对征税基数和征税比例进行特别规定来实现。在征税基数方面，对农民集体的特殊保护主要体现在对集体土地初次入市时初始价格的计算方式上。目前《调节金暂行办法》规定采用平均成本或者标准成本法进行计算，这种计算方式可能会降低应有的起算价值，进而损害农民利益。[①] 而实践中部分地区直接按照交易价格进行计算，且存在不同比例。因此，在制定土地增值收益税法时应当授权地方政府，对于集体土地初次入市的土地增值收益税的征税基数，可自主决定是按照增值收益或是按照交易价格进行征收。

在征税比例方面，除授权地方政府确定具体征收比例以外，还应当在土地增值收益税法中规定免征的特殊情形，以保护农民收益不受损。这主要是考虑到我国目前各地区集体经营性建设用地入市收益存在极不平衡的情况，具体标准应当参照“土地增值收益不应低于征地收益”的最低要求，如果土地增值收益严重低于征地收益，则应当免征土地增值收益税。

（二）明确政府管理职能

1. 政府应当对集体收益分配进行指导性规定

政府在对集体土地入市收益收取税收后，应当将集体内部对入市收益分配的决定权全部交由土地所有人，即集体成员。但是目前我国集体经济组织尚不完善，可能会被少部分人把持团体利益，进而成为侵蚀个人利益的工具。[②] 但相关法律法规的缺失并不能成为行政权力干预集体自治内容的理由，应当在进行农村建设的同时，推进集体经济组织相关立法。未来立法可以授权地方政府对土地入市收益的集体提留比例及用途进行指导性规定，但是地方政府不能限制和干涉集体成员经过合法程序所作出的集体收益分配决议。

2. 采用收益分配方案备案制

集体土地的所有权人是农民集体，其相关权益由集体经济组织代为行使，政府对

① 参见吴昭军《集体经营性建设用地土地增值收益分配：试点总结与制度设计》，《法学杂志》2019 年第 4 期。

② 参见陈小君《我国农民集体成员权的立法抉择》，《清华法学》2017 年第 2 期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

于集体决议的土地收益分配方案没有决定权。在《土地管理法》修正之前，有学者认为可以借鉴原第15条之规定，对集体经营性建设用地入市进行行政审批。[①] 但是《土地管理法》经修正后删除了报政府审批的要求。因此，不应当将政府审批作为土地收益分配方案的程序要求，而考虑到后续的确权、收税等问题，为了方便行政管理，应当采取行政备案制度。

（三）为未来立法预留空间

目前我国法律仅对集体经营性建设用地入市进行了确认，而对宅基地腾退入市等问题尚未确认，农村集体经济组织成员权的确定等历史遗留问题依旧未解决。这些问题的解决关系到集体经营性建设用地入市收益分配的实施。在对集体经营性建设用地入市收益分配制定法律时，对需要依靠其他法律制度进一步完善的内容应暂时不进行规定，为未来其他法律的配套实施预留空间。

《民法典》视野下的集体建设用地使用权

宋志红

一 《民法典》对集体建设用地使用权的规定及其意义

集体建设用地使用权是在农民集体所有土地上设立的以建设为使用用途的土地使用权，属于在集体建设用地上设立的用益物权。《民法典》物权编第十二章“建设用地使用权”之第344条在界定建设用地使用权时仍然维持了2007年《物权法》第135条之表述，并未将集体所有的土地纳入其中。尽管如此，考虑到《民法典》物权编第十二章的篇名冠之以宽泛的“建设用地使用权”而非“国有建设用地使用权”，以及该章最后一条也即第361条“集体所有的土地作为建设用地的，应当依照土地管理的法律规定办理”的规定，在权利体系上，集体建设用地使用权已经为《民法典》物权编第十二章“建设用地使用权”所涵括。故此，《民法典》物权编第十二章“建设用地使用权”部分虽然没有直接规定集体建设用地使用权的规则，其第344～360条之规定无法直接适用于集体建设用地使用权，[②] 但《民法典》的规定对完善集体建设用地使用权法律制度仍然具有重要意义：一是以《民法典》这一民事基本法的形式确立了集体建设用地使用权的用益物权属性，明确了集体建设用地使用权在民事权利体系

① 参见陶镕《集体建设用地使用权流转收益分配之法律探讨》，《湖南社会科学》2013年第1期。

② 参见宋志红《集体建设用地使用权设立的难点问题探讨——兼析〈民法典〉和〈土地管理法〉有关规则的理解与适用》，《中外法学》2020年第4期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中的地位，也即其属于建设用地使用权下的亚种类用益物权；二是通过第361条的转介规定明确了集体建设用地使用权法律适用上的特殊性，即并不依据《民法典》物权编第十二章其余各条的规定，而是“依照土地管理的法律规定办理”。之所以如此规定，是因为集体建设用地使用权制度改革仍在探索中，诸多具体制度设计并未完全成型，而《民法典》作为一部对稳定性要求很高的基本法，不适宜对这些正在变动的制度作出具体规定，留给“土地管理的法律规定”另行处理更有利于协调好改革和法治的关系。

故此，调整集体建设用地使用权的法律规则，首先是《民法典》物权编第361条指向的“土地管理的法律规定”，目前主要是《土地管理法》的有关规定。由于《土地管理法》第63条已经授权国务院针对集体建设用地制定具体办法，故国务院将来出台的有关具体办法也是调整集体建设用地使用权的重要法源。当前，《土地管理法实施条例》正在讨论修改过程中，[①] 在《土地管理法实施条例》修改完成以及国务院针对集体建设用地制定的具体规定出台之前，集体建设用地使用权设立和运行得以适用的法律依据主要是《土地管理法》第63条。其次，虽然说《民法典》物权编第十二章“建设用地使用权”中第344~360条之规定无法直接适用于集体建设用地使用权，但集体建设用地使用权作为《民法典》所确立的一种用益物权，《民法典》对民事权利和用益物权的一般性规定均得适用，且将来“土地管理的法律规定”在供给集体建设用地使用权的权利运行规则时亦须遵循《民法典》关于民事权利和用益物权的基本原则和一般的强制性规则，在对《土地管理法》等法律中关于集体建设用地使用权的民事规则予以解释时，也须遵循《民法典》的基本原则和精神。

二 《民法典》视野下集体建设用地使用权的设立主体

集体建设用地使用权的设立，是指土地所有权人设立具有用益物权属性的集体建设用地使用权并让渡给土地使用者的行为。集体建设用地使用权作为意定物权，其设立主体为合同的双方当事人：作为甲方的土地所有者和作为乙方的土地使用者。作为乙方之土地使用者的情形比较简单，依据《土地管理法》的规定，任何单位或者个人都具备成为土地使用者的资格，并无特别限制。换言之，任何自然人、法人、非法人组织都有资格成为集体建设用地使用权的权利人。但在交易中，由于土地使用者同时也是即将进行土地开发、利用和经营的主体，法律法规可能会对从事特定的开发经营活动的主体有资质等方面的要求，从而对潜在土地使用者的资质构成限制。此外，有学者主张“集体内部的组织和成员在农村集体经营性建设用地使用权的出让中，有权

① 2020年3月30日，自然资源部就《土地管理法实施条例（修订草案）》（征求意见稿）公开征求意见。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

享有类似于共有人优先购买权的优先受让权”。[①] 作为甲方之土地所有者的情形则比较复杂，农民集体所有的特殊属性使其在所有权行使上与国有土地存在不同，实践中在设权之时往往面临谁是土地所有权人、谁来行使所有权、谁有权签订合同的困惑。结合《民法典》和《土地管理法》的有关规定，需明确如下事项。

首先，明确土地所有权的归属。《民法典》和《土地管理法》规定的集体土地所有权的主体包括乡镇农民集体、村农民集体、生产队农民集体三种情形，具体到待设权的集体建设用地地块，其土地所有权具体归属于哪一个农民集体，则由该农民集体作为设立集体建设用地使用权的主体。土地所有权的归属则依据地籍管理和确权登记的有关记载确定。

其次，明确土地所有权的代表行使主体。“农民集体”本身并没有明确的民事主体地位，其作为众多农民的集合体，也无法自己去行使土地所有权。依据《民法典》第262条规定，土地属于村农民集体所有的，由村集体经济组织或者村民委员会依法代表集体行使所有权；土地分别属于村内两个以上农民集体所有的，由村内各集体经济组织或者村民小组依法代表集体行使所有权；土地属于乡镇农民集体所有的，由乡镇集体经济组织代表集体行使所有权。同时，《民法典》第96、99、101条赋予了“农村集体经济组织”和“村民委员会”特别法人主体资格，消除了上述农民集体土地所有权的法定代表行使主体参与民事活动的主体资格障碍。但这一赋予“农村集体经济组织”和“村民委员会”特别法人主体资格而回避“农民集体”本身的主体地位的做法，使得“农民集体”被“隐身”于“农村集体经济组织”和“村民委员会”等法定代表主体之后。如果每一个拥有土地所有权的农民集体均成立了相对应的农村集体经济组织，运行机制健全，依法取得了特别法人资格，则可有效解决该农民集体的土地所有权行使机制问题。但实践中相当多的村组并未成立农村集体经济组织，或者虽然存在名义上的农村集体经济组织，但其运行机制并不健全，亦未能通过依法登记取得法人资格。

统计数据表明，截至2020年4月，全国有超过27万个集体经济组织领到登记证书，以便开展经营管理活动，[②] 但实际拥有集体土地所有权的村组集体则多达数百万个，大多数村组集体并不存在有效的农村集体经济组织。针对此种情况，《民法典》第101条第2款规定：“未设立村集体经济组织的，村民委员会可以依法代行村集体经济

① 房绍坤：《农村集体经营性建设用地入市的几个法律问题》，《烟台大学学报》（哲学社会科学版）2015年第3期。

② 参见韩长赋《国务院关于农村集体产权制度改革情况的报告——2020年4月26日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议上》，《农村经营管理》2020年第6期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

组织的职能。”但《民法典》第101条第2款的规定只适用于土地归属于村农民集体所有的情形，村民委员会在行政村一级设立，当村农民集体没有设立相对应的村级农村集体经济组织时，可以由村民委员会依法代行集体土地所有权。但在南方的诸多村庄，土地所有权归属于生产队（村民小组）农民集体的情形十分常见，如果该生产队（村民小组）农民集体没有成立相对应的农村集体经济组织，依据《民法典》第262条第（二）项的规定，只能由“村民小组”依法代表集体行使所有权，但《民法典》并未赋予“村民小组”特别法人资格，“村民小组”的民事主体地位存疑。此时，生产队（村民小组）农民集体土地所有权的行使机制便出现了法律上的障碍或者说空白。此时，在该生产队（村民小组）及时成立相对应的农村集体经济组织便成为一项十分迫切的任务，在此之前，作为权宜之计，只能通过民主决策程序授权其他主体（例如村民委员会、村级集体经济组织等）代理其行使土地所有权。

最后，明确集体决定的程序。《民法典》第261条第2款要求农民集体在行使集体所有权涉及成员权益重大事项时，应当履行集体决议程序，虽然没有明确列举集体建设用地使用权设立事项，但集体建设用地使用权的设立显然属于与集体成员权益相关的重大事项。结合《土地管理法》第63条第2款，集体建设用地使用权的设立属于《民法典》第261条第2款第（五）项“法律规定的其他事项”。故此，无论土地所有权归属于哪一级农民集体，也无论是由农村集体经济组织还是由村民委员会代表行使，农民集体在设立集体建设用地使用权之前均须履行集体决议程序。依据《土地管理法》第63条第2款的规定，应当“经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意”。值得探讨的是，该处“本集体经济组织成员的村民会议”的表述将村民会议（村民代表会议）和农村集体经济组织的成员会议混杂了：村民会议（村民代表会议）应对应村民或村民代表，农村集体经济组织成员会议则应对应成员，此处应当召开的到底是村民会议还是农村集体经济组织成员会议？“三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意”的分母到底是全体成员（全体村民代表）还是符合法定人数要求的参会人员，文义上不无歧义，实践操作中也存在不同理解，有待进一步明确。①

三 《民法典》视野下集体建设用地使用权的设立方式

对于国有建设用地使用权的设立方式，《民法典》物权编第347条第1款规定：“设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。”从实践看，国有建设用地使

① 参见宋志红《集体建设用地使用权设立的难点问题探讨——兼析〈民法典〉和〈土地管理法〉有关规则的理解与适用》，《中外法学》2020年第4期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

用权的设立方式包括出让、划拨、作价出资（入股）等方式。从法律效果看，作价出资（入股）可以视为出让的一种特殊类型，只不过出让人获取的对价不是出让金而是被出资（入股）企业的股权。此外，国有土地有偿使用实践中还存在一种特殊的“租赁”方式。对于集体建设用地使用权，《民法典》未明确其设立方式。《土地管理法》第 63 条第 1 款规定，土地所有权人可以将集体经营性建设用地“通过出让、出租等方式交由单位或者个人使用”。社会各界对于出让作为集体建设用地使用权设立的主要方式，并无疑义；作价出资（入股）既然在法律效果上等同于出让，当然亦能作为集体建设用地使用权的设立方式。值得探讨的是出租（租赁）两种方式。

一方面，出租是集体经营性建设用地市场化配置的重要方式，在试点实践中深受交易双方欢迎，《土地管理法》第 63 条第 1 款也明确规定了此种交易方式。另一方面，出租作为一种民事交易方式，需要置于《民法典》的视野下检讨其法律性质和效果。事实上，《民法典》遵循物债二分的原则明确区分出让和出租两种交易方式。首先，出让属于物权设定方式，可以创设属于用益物权的集体建设用地使用权。出租则是债权设定方式，只能设定债权属性的集体建设用地租赁权；其次，出让适用《民法典》物权编，权利义务关系遵循物权法定原则，最长期限可达 40 年、50 年或 70 年不等，以出让方式设定的建设用地使用权作为独立的用益物权具备转让、抵押等权利处分权能；出租则适用《民法典》合同编，权利义务关系由当事人在合同中自由约定，期限不得超过 20 年，承租人取得的土地债权受合同相对性约束，未经出租人同意不得转租，更不得抵押。因此，《土地管理法》第 63 条第 1 款虽然将出让和出租并列作为集体经营性建设用地有偿使用的方式，但第 3 款和第 4 款在权能规定上对二者实行了区别对待：只有“通过出让等方式取得的集体经营性建设用地使用权可以转让、互换、出资、赠与或者抵押”，通过出租方式设立的权利则不具备此种权能。这一规定再次明确区分了出让和出租，坚守了“出租”方式的债权行为属性。可见，出租虽然是集体建设用地有偿使用的方式，但并非集体建设用地使用权的设立方式。

值得注意的是，原国土资源部于 1999 年印发的《规范国有土地租赁若干意见》将“租赁”规定为国有建设用地使用权的设立方式，规定以租赁方式设立的建设用地使用权不仅期限可以超越 20 年，而且承租人还享有转让和抵押的权利，从而使得国有建设用地有偿使用领域长期存在一种特殊的“租赁”出让方式。但此种“租赁”与民法上的“租赁”或“出租”在法律效果上实则存在很大的不同。在 2007 年《物权法》颁布并明确规定物权法定原则（依据该原则，行政法规和部门规章不具备创设物权的权限）之后，该意见就应被废止或者修正。可惜的是，该意见至今尚未被清理，土地管理实践中也就一直存在迥异于民法上之租赁的“特殊租赁”。在集体经营性建设用地入

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

市改革实践中，不少地方进一步将此种“特殊租赁”规定为集体建设用地使用权的设立方式。笔者认为：租赁为世界各国通行概念，在我国法律上也有明确的含义，在土地管理实践中硬生生地创造出一个不同于上位法规定的“特殊租赁”，会造成法律概念的混乱，亦超越了行政法规和部门规章的权限。趁《民法典》颁布实施之机，应及时清理《规范国有土地租赁若干意见》。

《民法典》用益物权分编的解释论三题*

黄　忠

《民法典》的颁布为中国民法学从立法论向解释论的转型提供了坚实基础。科学阐释好《民法典》的制度内涵是实施好《民法典》的必要前提。《民法典》用益物权分编是极具本土特色的规范群，如何科学、妥当解释好《民法典》用益物权的相关规范就当然成为后《民法典》时代民法解释论研究的重要内容。

一　体系解释：用益物权人是否具有独立的补偿资格？

《民法典》第327条规定：“因不动产或者动产被征收、征用致使用益物权消灭或者影响用益物权行使的，用益物权人有权依据本法第二百四十三条、第二百四十五条的规定获得相应补偿。”第338条进一步规定：“承包地被征收的，土地承包经营权人有权依据本法第二百四十三条的规定获得相应补偿。”依据《民法典》的上述两条规定，因不动产或者动产被征收、征用致使用益物权消灭或者影响用益物权行使的，用益物权人有权获得相应补偿。但前述条文并未言明用益物权人是否具有独立的补偿资格。换言之，用益物权人是可以与所有权人一并作为征收、征用的补偿对象，抑或征收、征用的补偿主体只能是所有权人，用益物权人只能向所有权人主张分配？

以土地征收为例，《土地管理法》只规定了土地征收补偿的项目和标准，未明确补偿对象，由此导致实践中常常将土地补偿费的请求权人或受领权人理解为土地的所有权人，即土地征收后的土地补偿费归农村集体经济组织所有，集体经济组织再根据民主程序决定分配方案。我国很多地方的地方性法规也据此作出规定。如此一来，土地补偿费的分配纠纷就成了本集体经济组织内部的分配问题。《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔2005〕6号）第24条第1句也规定：“农村集体经济组织或者村民委员会、村民小组，可以依照法律规定的民主议定程序，决定在本集体经济组织内部分配已经收到的土地补偿费。”

* 本文是国家社科基金重点项目“中国民法上的中国元素研究”（18AFX015）的阶段性成果。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

然而，现在有学说强调土地承包经营权人可以基于其用益物权单独主张征地补偿，即该请求权独立于土地所有权人的征地补偿请求权。[①] 并指出，在《物权法》颁布之前，诸如土地承包经营权、建设用地使用权等用益物权并未被立法明定为一种独立的物权类型。然而，《物权法》不仅专门明确了物权、用益物权的概念，而且还在其第十一章规定了“土地承包经营权”，将其作为用益物权对待，明确了其物权属性，[②] 这表明土地承包经营权已经是一项长期稳定的财产权利，不是一种短期的财产利益。既然土地承包经营权已经成为长期稳定的物权，因而应当将土地承包经营权人作为被征收人看待。[③]

在比较法上，土地征收的补偿对象除了所有权人外，还包括享有他项权利的人，甚至因征收而使其权利受到影响的人都能够成为被征收人。比如，在德国，“作为征收客体的财产的范围十分广泛，凡是属于基本法第 14 条第 1 款第 1 句的保护范围并且因此属于该条第 3 款规定的私权利中具有财产价值的所有权利，以及特定条件下公权利中具有财产价值的权利都包括在内”。[④] 相应地，这些权利人也就成为当然的补偿对象。

就逻辑而言，征收补偿对象是由征收的客体决定的。在我国，理论上一般认为，征收的客体是财产的所有权，[⑤] 因此，征收补偿的对象应当是所有权人。[⑥] 财产之上的其他权利人，比如担保物权人、债权人等并不是补偿的对象。即使因为征收而导致担保物、租赁权等消灭，也应当通过担保物权人、承租人向所有权人的追偿来获得救济。比如，2011 年 1 月 21 日《国有土地上房屋征收与补偿条例》就删除了《城市房屋拆迁管理条例》中有关房屋承租人补偿权利的条款。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第 80 条也规定，“在抵押物灭失、毁损或者被征用的情况下，抵押权人可以就该抵押物的保险金、赔偿金或者补偿金优先受偿”。实际上，单从《物权法》第 121 条、第 132 条以及《民法典》第 327 条和第 338 条的文义来看，包括诸如土地承包权人在内的用益物权人有权获得“相应补偿”这一表述本身并没有表明用益物权人具有独立的补偿资格。

---

① 参见姜爱林、李强、陈启华《基于土地征收视角的土地承包经营权补偿问题研究》，《重庆国土资源》2007 年第 3 期；王利明《〈物权法〉颁布后土地承包经营权征收中的若干法律问题》，《法学》2009 年第 5 期；周江洪《土地承包经营权独立补偿问题研究——以〈物权法〉与〈土地管理法〉的衔接为中心》，《兰州大学学报》（社会科学版）2011 年第 5 期；李昱《土地承包经营权独立补偿问题研究》，《农业经济》2012 年第 4 期；王克稳《我国集体土地征收制度的构建》，《法学研究》2016 年第 1 期。

② 参见周江洪《土地承包经营权独立补偿问题研究——以〈物权法〉与〈土地管理法〉的衔接为中心》，《兰州大学学报》（社会科学版）2011 年第 5 期。

③ 参见王利明《〈物权法〉颁布后土地承包经营权征收中的若干法律问题》，《法学》2009 年第 5 期。

④ 〔德〕哈特穆特·毛雷尔：《行政法学总论》，高家伟译，法律出版社，2000，第 680 页。

⑤ 参见王利明《物权法》，中国人民大学出版社，2015，第 98 页。

⑥ 参见朱岩、高圣平、陈鑫《中国物权法评注》，北京大学出版社，2007，第 199 页；最高人民法院物权法研究小组编著《〈中华人民共和国物权法〉条文理解与适用》，人民法院出版社，2007，第 162 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

当然，从现实角度看，在自然资源公有制的前提下，如果不承认用益物权人的独立地位，并将征收的客体局限为所有权，那么用益物权人就会因为欠缺独立的补偿地位而无法有效参与征收的协调，其权益难免会受到损害。在一定程度上，我们甚至可以认为，自然资源公有制背景下的用益物权其实具有类似于私有制下“所有权”的法律地位。否则，在土地征收中，若认为该土地补偿费中已包含了土地承包经营权的补偿，那么土地补偿费的合理分配程序就应当是先从该土地补偿费中析分出补偿土地承包经营权的那部分补偿费，然后才能依社员权的法理和《村民委员会组织法》的规定就剩余部分的补偿费依民主程序决定分配方案，否则就有可能导致以多数人的议决分配他人财产之嫌，也不符合财产共有的一般法理，面临无权处分之困境。[①] 因此，无论是从保护用益物权人利益，还是基于我国自然资源公有制的现实，抑或妥当处理征收纠纷的角度，似乎都应当将用益物权人作为独立的补偿对象。为此，在立法论上，似乎有必要进一步明确用益物权人有权依法“直接”获得相应补偿，甚至系统性地明确他物权人和相关利害关系人（比如承租人）的补偿地位。

然而，将用益物权人作为独立补偿主体以后，还需要作进一步的体系化思考。一方面，如果将用益物权人作为独立的补偿主体，则需进一步明确用益物权的价值。从物权法的逻辑上讲，用益物权系由所有权派生而来。在自然资源公有制背景下，用益物权至多也只能是具有“类似”所有权的地位，因此不能完全按照土地所有权的标准来确定补偿标准，否则就会架空所有权人的地位，从根本上否定公有制的意义。就此而言，用益物权的价值问题涉及自然资源内涵的发展权归属与配置问题，值得进一步研究。另一方面，从体系上考虑，一旦认定土地承包经营权人具有独立的补偿地位，我们又该如何认识经过登记的土地经营权人的补偿地位呢？如果按照前述认识，至少经过登记的土地经营权也有物权属性，[②] 权利人自然也应作为独立的征收补偿主体，但若如此认识，则是否会产生集体土地所有权人、土地承包经营权人、土地经营权人同时作为征收补偿主体的复杂问题？如果考虑到《民法典》上的多种用益物权类型，诸如居住权人、地役权人等是否也同样具备独立的补偿资格？

二　历史解释：《民法典》中的变更登记的双重内涵

《民法典》第355条规定：“建设用地使用权转让、互换、出资或者赠与的，应当向登记机构申请变更登记。”第365条规定：“已经登记的宅基地使用权转让或者消灭

① 参见周江洪《土地承包经营权独立补偿问题研究——以〈物权法〉与〈土地管理法〉的衔接为中心》，《兰州大学学报》（社会科学版）2011年第5期。

② 参见崔建远《物权编对四种他物权制度的完善和发展》，《中国法学》2020年第4期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的，应当及时办理变更登记或者注销登记。”需要指出的是，《民法典》第355条、第365条的规定并不意味着其已经改变了“变更登记”的内涵，即试图用“变更登记”来指称“转移登记”。就《民法典》的体系和历史而言，《民法典》中的变更登记其实是一个具有双重内涵的概念，既针对权属发生转移时的转移登记，也包括了权属并未发生转移时的变更登记。比如，按照《民法典》第385条的规定，“已经登记的地役权变更、转让或者消灭的，应当及时办理变更登记或者注销登记”。很明显，本条就直接用变更登记来囊括地役权变更与转让两种情形。

从历史角度而言，《民法典》之所以没有严格区分转移登记与变更登记，而是将二者统称为变更登记，其实是与《民法典》的编纂定位有关的。《民法典》的编纂定位决定了《民法典》在很多具体规定上会采取继承的态度，即将既有民事法律的规定予以沿袭。不难发现，《民法典》第355条、第365条和第385条其实是对《物权法》第145条、第155条和第169条的直接继承，在具体内容上均未有任何的修改。因此，《民法典》有关变更登记的认识其实是对《物权法》中变更登记规定的延续。

在《物权法》制定时，我国并未建立统一的不动产登记制度，因此对有关登记类型的认识比较粗糙，并未构建统一、规范的登记术语体系。比如，1989年《土地登记规则》中的登记类型除了初始登记外，就只有变更登记一种情形，因而《土地登记规则》中的变更登记就涵盖了初始登记以外的各种登记情形，既包括变更登记（第25条），也包括转移登记（第28条），甚至还包括更正登记（第35条）。正是由于这一历史原因，所以《物权法》就此采取了模糊的态度，没有严格区分转移登记与变更登记，而以变更登记统称二者。《物权法》颁布后，原国土资源部虽然公布了《土地登记办法》，但依然没有澄清变更登记与转移登记的差异。按照《土地登记办法》第38条的规定，变更登记是指因土地权利人发生改变，或者因土地权利人姓名或者名称、地址和土地用途等内容发生变更而进行的登记。《土地登记办法》第39条还明确规定，依法以出让、国有土地租赁、作价出资或者入股方式取得的国有建设用地使用权转让的，当事人应当持原国有土地使用证和土地权利发生转移的相关证明材料，申请国有建设用地使用权变更登记。可见，《土地登记办法》中变更登记的含义相当宽泛，既包括了土地权利人发生改变的情形，也包括了因土地权利人姓名或者名称、地址和土地用途等内容发生变更的情形。

然而，上述对变更登记含义的宽泛理解显然会对不动产统一登记制度的构建产生不利影响，因此，要统一不动产登记就必须就此含义进行科学化认识。事实上，在房屋登记领域，我国较早就对转移登记与变更登记作了区分。比如，1997年《城市房屋权属登记管理办法》与2008年《房屋登记办法》就区分了转移登记与变更登记。为了

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

落实《物权法》中不动产统一登记制度的要求，2014年国务院公布了《不动产登记暂行条例》。《不动产登记暂行条例》第3条就不再以变更登记来指称转移登记，而是直接将变更登记与转移登记予以并列。2016年公布的《不动产登记暂行条例实施细则》则进一步明确区分了转移登记与变更登记。按照《不动产登记暂行条例实施细则》第26条的规定，只有在“权利人的姓名、名称、身份证明类型或者身份证明号码发生变更”“同一权利人分割或者合并不动产”“共有性质发生变更”等情形中，不动产权利人才可以向不动产登记机构申请变更登记。很明显，变更登记主要针对的是不动产权利人的信息变更、不动产的自然状况变更以及不动产权利的内容变更。据此，无论是《民法典》第355条中的建设用地使用权转让、互换、出资或者赠与，抑或是第365条和第385条中的宅基地使用权和地役权转让，均不符合上述申请变更登记的条件。

实际上，《不动产登记暂行条例实施细则》第27条已明确规定，因“买卖、互换、赠与不动产”“以不动产作价出资（入股）”“法人或者其他组织因合并、分立等原因致使不动产权利发生转移”“继承、受遗赠导致权利发生转移”和“因人民法院、仲裁委员会的生效法律文书导致不动产权利发生转移”等情形导致不动产权利转移的，当事人可以向不动产登记机构申请转移登记。可见，转移登记与变更登记的区别在于转移登记前后的权利主体会发生变化，而变更登记前后的权利主体保持一致。在变更登记中，只是权利主体的信息（如权利人姓名、名称等）发生了变化，或者是权利客体的状况（如不动产名称、用途、面积等）或权利的内容（如权利期限、抵押权担保的范围、主债权数额等）发生了变化，但变更登记前后的权利人始终不变。据此而言，《民法典》第355条、第365条中的“变更登记”以及第385条中的“地役权转让”情形下的“变更登记”均应理解为“转移登记”。

三　目的（功能）解释：以地役权、居住权指引土地制度的改革

习近平总书记强调，凡属重大改革都要于法有据。作为基础性法律的《民法典》不仅是改革成果的系统总结，更是引领全面深化改革发展的重要指针。土地制度改革是当前全面深化改革的重要内容。要切实发挥《民法典》促进改革发展的功效，让用益物权分编的制度规范成为改革发展的重要工具，我们就应善于运用目的（功能）解释方法。

例如，为了有效推进地票（用地指标）交易，化解地票交易的合法性危机，有必要将地票交易纳入地役权的范畴。以地役权来定性地票交易不仅可以为地票交易确立物权法上的依据，有效化解地票交易合法性不足的质疑，而且可以为实践中关于地

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

票的登记以及转让、抵押等问题找到物权法上的解决方案，有利于进一步深化地票交易制度的改革。[①] 随着地票交易的不断推进，上述认识在《民法典》框架下更应被接受。

不仅如此，为了促进宅基地“三权分置”改革，可通过《民法典》新设的居住权制度来为保障宅基地农户资格权提供规范依据。宅基地“三权分置”改革需要严守土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损“三条底线”，并以保障农民“户有所居”为基础。如何保障农民“户有所居”，不仅需要政策的支持，更需要法律，尤其是《民法典》的守护。按照《民法典》第366条的规定，居住权人有权按照合同约定，对他人的住宅享有占有、使用的用益物权，以满足生活居住的需要。很明显，“户有所居”的目标与居住权的内容完全契合，因此，宅基地“三权分置”改革完全可以通过居住权来实现。以《民法典》的居住权制度来指引宅基地“三权分置”改革不仅有助于保障农民“户有所居”，而且有利于进一步发挥好居住权的现实功效，可谓一举两得。

《民法典》中土地制度适用应关注的几个问题*

单平基

《民法典》的出台，是从解释论视角探讨土地制度新概念、新规范的逻辑起点。这有赖于对基本法律概念和规则的阐释。在适用时，不患适用者拘泥于逻辑，唯恐其心中尚无概念。其中，承包地“三权分置”入典、住宅建设用地使用权续期、土地承包经营权和土地经营权的融资担保等问题，作为土地制度的重要组成部分，均需要从解释论角度予以阐释，以助推相关规范的具体适用。

一 承包地“三权分置”入典问题

继修正后的《农村土地承包法》首次将承包地“三权分置”纳入立法规范之后，《民法典》第339~342条等条文对此也进行了规范。承包地“三权分置”入典，预示着对此问题的探讨，应由立法论向解释论层面转变，并接受实践层面对此制度成效的检验。

承包地“三权分置”入典，是《民法典》对农村土地法制改革成果的一种法典确

① 参见黄忠《地票交易的地役权属性论》，《法学》2013年第6期；黄忠《地票制度研究》，法律出版社，2019，第86~117页。

* 本文是国家社科基金项目“《民法典》适用中的承包地权利体系解释论”（20BFX102）的阶段性成果。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

认，对未来农村土地法制改革的走向将起到重要引导作用。《民法典》确立的承包地“三权分置”权利结构中，土地经营权生发于土地承包经营权的债权性流转。具言之，《民法典》第339条承袭了《农村土地承包法》第36条的规定，在农村土地集体所有权、农户土地承包经营权之“两权分离”的基础上，基于土地承包经营权人以出租、入股或其他方式向他人流转土地经营权，而使承包地权利体系呈现农村土地集体所有权、土地承包经营权、土地经营权之“三权分置”的结构形态。从规范解释来看，《民法典》第339条关于土地经营权的生成，限于土地承包经营权的债权性流转，而土地承包经营权的物权性流转，诸如《民法典》第334条规定的互换、转让，并未生成新的土地经营权，而是引起土地承包经营权这一用益物权的整体性变动。[①] 另外，《民法典》舍弃土地承包经营权的转包，仅规范出租形式，防止二者在制度设计上的重合，具有合理性。[②]

土地经营权因应承包地“三权分置”法制改革而来，生发于土地承包经营权。在法律概念选择上，《民法典》未吸纳《农村土地承包法》第9条的立法表述创设“土地承包权”，未改变土地承包经营权的概念称谓，[③] 构建了“农地集体所有权（自物权）—土地承包经营权（用益物权）—土地经营权（债权）”的结构形式，[④] 值得赞同。土地经营权的流转取得，无须取得农村集体土地所有权人的同意，但除需要受土地承包经营权期限限制外，不能因土地经营权的生成而改变农地的用途。

应注意，在农村土地法制实践中，承包地“两权分离”与“三权分置”权利结构会长期并存。当土地承包经营权人自己直接经营承包地，而不流转承包经营权时，就不会生成新的土地经营权，[⑤] 仍呈现承包地“两权分离”的结构形态。这可能是基于客观上土地承包经营权不适于流转，例如，山地不适宜采用机械耕作方式和规模经营，也可能是基于农户主观层面对直接经营的自主选择。换言之，只有在土地承包经营权发生债权性流转时，方有生成土地经营权的可能，即呈现承包地“三权分置”权利结构。在此意义上，“土地承包经营权制度对大陆土地改革及公有制的发展产生重大的效用”。[⑥]

土地经营权的生成是基于土地承包经营权发生流转，体现为出租、入股或者其他

① 关于土地经营权的债权定性，参见单平基《“三权分置”中土地经营权债权定性的证成》，《法学》2018年第10期；单平基《“三权分置”理论反思与土地承包经营权困境的解决路径》，《法学》2016年第9期。

② 参见单平基《〈民法典物权编（草案）〉之土地承包经营权的评析和完善》，《山东社会科学》2019年第2期。

③ 关于主张继续沿用土地承包经营权概念的详细论证，参见单平基《分解、舍弃抑或改造：〈民法典〉编纂中土地承包经营权的定位》，《南京农业大学学报》（社会科学版）2020年第3期。

④ 关于承包地“三权分置”权利结构的立法选择，参见单平基《民法典编纂中农地“三权分置”的立法选择》，载刘云生主编《中国不动产法研究》（总第19辑），社会科学文献出版社，2019，第83~99页。

⑤ 参见崔建远《物权编对四种他物权制度的完善和发展》，《中国法学》2020年第4期。

⑥ 王泽鉴：《中国民法的特色及解释适用》，《法律适用》2020年第13期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

方式，限于债权性流转。可以预见，学界关于土地经营权定性的争论，不会因《民法典》的通过就戛然而止。尤其是《民法典》采取了以土地经营权期限的长短（以5年为界）决定其权利性质的定性方式，使得对土地经营权的定性愈加模糊。《民法典》第341条承袭了《农村土地承包法》第41条的规定，从该条规范看，它实际是以存续期限的长短确定土地经营权的属性，具体以5年为界，5年以上的土地经营权经登记可被认定为物权，而5年以下的土地经营权由于期限较短，则定性为债权。①

但是，期限的长短仅能作为判定物权和债权的参考性因素，而很难作为权利定性的决定性因素。例如，所有权固然具有恒久性，但当所有物或因自然原因消灭，或因法律原因被处分之时，该所有权于权利人处所实际存续期限之长短，尚难以确定。又如，租赁权的期限最长可达20年（《民法典》第705条），但其本质是一项债权。再如，担保物权从属于债权，其期限亦常受债权期限影响，有时也难谓长久。循此，期限的长短难以成为权利定性的依据。

二　住宅建设用地使用权续期问题

住宅建设用地使用权到期后如何续期，涉及每一位城镇居民的切身权益，而续期费用是否缴纳及如何缴纳则不仅关涉法律，更是与一个国家的土地制度管理、财政、税收等密不可分，在本质上都反映了一国法律对公民财产权利的尊重程度，而非仅是学术问题。② 从《民法典》第359条第1款的文义看，容易使人产生住宅建设用地使用权到期后需缴纳费用的印象。对此问题，应慎之又慎。毕竟，在取得住宅建设用地使用权时，权利人所缴纳的土地出让金已非常高昂，甚至超越一些国家的地价，加之当前在一线或二线城市已异常高的房价，容易使人们产生对已取得的合法财产不确定性的担忧，构成了我国人民提高基本生活水平的障碍。③

需要注意，依据《民法典》第359条第1款，能够对住宅建设用地使用权“续期费用的缴纳或者减免”予以规范的最低层面的制度位阶，应当是行政法规。依据《中华人民共和国宪法》第89条第1项，行政法规由国务院依据宪法和法律制定，属于实现国家管理职能的重要手段。依据《中华人民共和国立法法》第9条，除法律立法保留事项外，全国人民代表大会及其常务委员会有权作出决定，授权国务院根据实际需

① 在2020年1月16日上午由全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会民法室组织召开的《中华人民共和国民法典·物权编（草案）》研讨会上，有关领导介绍了这种立法计划和立法目的。转引自崔建远《物权编对四种他物权制度的完善和发展》，《中国法学》2020年第4期。

② 参见彭诚信《〈民法典〉物权编的进步、局限与未来》，《法制与社会发展》2020年第4期。

③ 参见彭诚信《有关住宅建设用地使用权自动续期的几个问题浅析》，载钟杨主编《实证社会科学》（第二卷），上海交通大学出版社，2016，第9~16页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

要，对其中的部分事项先制定行政法规。行政法规的制定主体是国务院，其效力仅次于宪法和法律，高于部门规章和地方性法规。这也意味着地方政府、国务院各部委无权出台关于住宅建设用地使用权续期费用缴纳或减免的地方性法规、部门规章、地方政府规章或其他规范性文件。

另外，采取何种续期方式，亦是需要考虑的问题。其一，实践中，住宅建设用地使用权的期限不一，最高出让年限为70年（《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第12条第1项），40年或50年者并不鲜见，最短亦有20年者。对此，是否应如学者建议的将期限一律延长至70年，之后再无偿续期?[①] 此种立法建议旨在实现形式上的平等，但是，面对纷繁复杂的实践，“有的当事人不愿延长，法律将如何处理，是强制延长还是保持现状”?[②] 在实际操作上，恐难实现。其二，是否应采取以原来期限为界点分别延长？是否原为70年者再续期70年，原为50年者再续期50年，并以此推之，即原来期限多长再续多长？其三，续期期限不同时，同类地块续期的费用如何确定？这些问题都需要在认真调研的基础上，再予确定。

实际上，《民法典》第359条第1款作为引致性规范，将“续期费用的缴纳或者减免”交给以后的法律、行政法规调整，续期费用究竟如何缴纳或减免的幅度仍无法明确。[③] 应当说，续期费用的缴纳或减免，不仅关涉每个城镇居民的切身权益，而且会对全体民众产生重要影响。毕竟，这既会影响到潜在购房者的选择，同时，续期费用也可能用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、支农支出和城市建设支出等领域，关系到不特定人的利益。鉴于此，我们建议，将来对此问题以位阶更高的法律（而非行政法规）进行规范，实为最佳选择。

三　承包地使用权融资担保问题

土地承包经营权可作为抵押客体。《民法典》第395条对允许抵押的财产进行了列举式规定，其中，删除了《物权法》第180条第1款中的“以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权”。从表面看，这似乎给人此种权利不得作为抵押客体的印象。但事实并非如此。此项立法变化，究其原因，主要是基于《民法典》第399条在“不得抵押”的财产范围中，删除了《物权法》第184条中的“耕地”使用权。既然耕地使用权已纳入可抵押财产的范围，那么，因应法律的体系性和科学性要求，就无必要再列举“荒地”的土地承包经营权可予抵押。相反，《民法典》若再予

① 参见杨立新《住宅建设用地使用权期满自动续期的核心价值》，《山东大学学报》（哲学社会科学版）2016年第4期。

② 孙良国：《自动续期制度设计中的公平考量》，《法制与社会发展》2017年第6期。

③ 参见房绍坤《民法典物权编之检视》，《东方法学》2020年第4期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

规定，就属画蛇添足。

目前，尚存在争议的问题是，在土地承包经营权未流转时，用作融资担保的客体，是否包括土地承包经营权中未发生分离的“土地经营权”？毕竟，按照《农村土地承包法》第 47 条第 1 款，“承包方可以用承包地的土地经营权向金融机构融资担保，并向发包方备案”。对此，有学者持肯定态度，认为“在土地承包经营权尚未被分成土地承包权和土地经营权的情况下，土地承包经营权人（农户）在融资程序中将土地经营权独立出来，并抵押给（在承认土地经营权为物权的理论体系下）或出质给（在把土地经营权作为债权的理论体系下）出借人”。[①] 有学者持否定态度，主张“承包方之承包地的土地经营权融资担保实质上仍是基于土地承包经营权设定抵押”。[②]

此种情形下，并未生发出新的土地经营权，农户享有的权利在本质上仍然应被认定为土地承包经营权。一种可能的解释是，将其理解为农户以“经营权能”进行担保。但是，在此项权能未与土地承包经营权脱离，并未形成新的权利类型的情况下，仅以权能进行融资担保，在民法理论上难以成立。循此，《农村土地承包法》第 47 条第 1 款前半段承包农户用土地经营权设立担保，应解读为以土地承包经营权设立担保权，而非以经营权设立担保权。[③]

关于土地经营权融资担保的形式，《农村土地承包法》第 47 条使用了“融资担保”的模糊性用词，对具体的担保形式并未明确，给司法实践提出了挑战。有学者认为，土地经营权采取抵押形式，在不转移对农地占有的情况下，就可达致融资目的，不妨碍新型经营主体对农地继续占有、使用和收益。故此，以经营权为客体设定的担保权应当被界定为抵押权。[④] 当前，《民法典》第 381 条已确认了土地经营权可以抵押形式进行融资担保。

尚存在争议的问题是，土地经营权可否作为质权的标的。有学者持反对意见，认为设定质权后经营权人将丧失对农地的直接占有和经营，[⑤] 土地经营权之上不可设定质权。[⑥] 有学者主张视土地经营权的定性决定采取的融资担保形式，“在利用土地经营权融资时，已经取得土地经营权的实际占有、使用、收益承包地之人可以是抵押人

① 崔建远：《物权编对四种他物权制度的完善和发展》，《中国法学》2020 年第 4 期。

② 房绍坤、林广会：《解释论视角下的土地经营权融资担保》，《吉林大学社会科学学报》2020 年第 1 期。

③ 关于土地经营权融资担保的法律实现路径的详细论证，参见单平基《土地经营权融资担保的法实现——以〈农村土地承包法〉为中心》，《江西社会科学》2020 年第 2 期。

④ 参见何宝玉主编《中华人民共和国农村土地承包法释义》，中国民主法制出版社，2019，第 117 页；高圣平、王天雁、吴昭军《〈中华人民共和国农村土地承包法〉条文理解与适用》，人民法院出版社，2019，第 311 页。

⑤ 参见高圣平《民法典担保物权制度修正研究——以〈民法典各分编（草案）〉为分析对象》，《江西社会科学》2018 年第 10 期。

⑥ 参见高圣平《土地经营权制度与民法典物权编编纂——评〈民法典物权编（草案二次审议稿）〉》，《现代法学》2019 年第 5 期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（在承认土地经营权为物权的理论体系下）或出质人（在把土地经营权作为债权的理论体系下）”。①

从功能主义看，土地经营权可采取权利质押的方式进行融资担保。实际上，参与立法者也认为，《农村土地承包法》第47条中“融资担保”的形式，应涵括抵押和质押，以回应承包农户融资难困境。② 以土地经营权为客体设置的质权，其本质上应定性为权利质权。以土地经营权设定质权，分两种情形：一是针对已取得此项经营权证书者，只要转移证书即可，无须转移对农地现实性的占有；二是针对未取得权利证书者，可通过登记方式设立质押，以避免质权的设立钳制土地经营权人对农地的实际占有和经营。③

保留进城落户农民土地承包经营权的制度背景和价值*

姜红利

一 问题的提出

2018年修正的《农村土地承包法》新增了“不得以退出土地承包经营权作为农户进城落户的条件”这一规定。该条规定以“不得退出”为名对进城落户农民继续保留土地承包经营权进行了立法确认。立法不直接作出可以保留的肯定确认表达，背后有契合政策鼓励引导进城落户农民退出土地承包经营权的倾向。从政策和立法用语的选择来看，似乎是“不得已”才规定不得强制退出，而追求的最优目标则是进城落户农民可以自愿退出，即退出是最终目标，不得强制退出是现实选择。因此，分析“不得已”的理由则是解读进城落户农民保留土地承包经营权的重点。本文将以城镇化为背景分析进城落户农民土地承包经营权的制度安排，并以转变城镇化户籍决定论理念为出发点，通过区分成员权和财产权、户籍和成员资格等角度阐释进城落户农民土地承包经营权保留制度的独立价值，将其作为探索新型城镇化道路的一种理论突破。

2014年《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》明确指出，“现阶段，不得以退出土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权作为农民进城落户的条

① 崔建远：《物权编对四种他物权制度的完善和发展》，《中国法学》2020年第4期。

② 参见黄薇主编《中华人民共和国农村土地承包法释义》，法律出版社，2019，第201页。

③ 参见单平基《土地经营权融资担保的法实现——以〈农村土地承包法〉为中心》，《江西社会科学》2020年第2期。

* 本文是国家社会科学基金青年项目“农村集体非经营性资产运行法律机制研究”（20CFX039）的阶段性成果。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

件”。2015年《国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》要求引导农户“自愿退出”土地承包经营权。[①] 值得注意的是，该意见的政策用语由2014年的禁止强制退出转变为引导自愿退出，也体现了对进城落户农民自愿退出土地承包经营权的价值导向。

系统梳理历年政策，进城落户农民土地承包经营权的政策安排经历了由单纯强调权利退出扩展为权利多元流转的导向变迁。但不管具体政策如何变迁，促进进城落户农民户籍转化均是政策背后的目的导向，也正是这种户籍转化的导向使得地方实践和学界普遍以进城落户农民土地承包经营权的退出为改革试点和理论研究的重点，往往忽视了对进城落户农民土地承包经营权保留以及保留基础上的多元流转机制的关注。此种退出导向试图彻底割裂进城落户农民和农村土地的关系，意欲从根本上解决进城落户农民的户籍转化问题。

二　中国新型城镇化道路应逐渐转变户籍决定论理念

面对上述户籍人口转化的困境，一方面需要反思解决难题的对策是否恰当，另一方面也要重新理解城镇化的难题到底是什么，户籍人口城镇化率真的是中国城镇化道路的唯一决定因素吗。

（一）常住人口城镇化率指标与以人为核心的城镇化目标关联小

20世纪90年代以来，大量农民流入城镇工作，却难以真正融入城镇，此种城镇化进程反而凸显了农民工和城镇居民在城市公共服务享有上的不平等矛盾，产生了一系列诸如农民工子女入学、住房保障和身份认同等社会问题。仅仅强调常住人口的城镇化会凸显城乡矛盾，不利于城镇化所要达到的城乡社会的融合效果，由此产生的不平等效应也是和城镇化目标背道而驰的。户籍人口城镇化率的提高可以解决进城农民作为外来常住人口却不能在城镇平等享受公共服务产生的加剧城乡割裂等问题。因此，户籍人口城镇化率比常住人口城镇化率更能实现城镇化目标。同时，户籍人口城镇化率的提高对于稳定经济增长和促进社会和谐意义重大。因为落户农民可稳定提供市场所需劳动力，有利于稳定工资成本。此外，落户农民可以拉动扩大内需，稳定房地产市场，也有助于基础建设的稳健投资。

（二）户籍人口城镇化率逐渐难以胜任衡量城镇化的健康指标

相较于常住人口城镇化率，户籍人口城镇化率的确可以消除进城农民和原始城市居民无法平等享有公共服务的社会矛盾，却逐渐难以胜任扩大内需、稳定房地产市场的任务，将其作为衡量城镇化健康与否的唯一指标也逐渐显得不合时宜。户籍人口城

① 参见《国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》，《中华人民共和国国务院公报》2015年第23期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

镇化率已难以胜任衡量城镇化的健康指标，理由如下。

其一，在城乡一体化建设背景下，农村户籍所附着的社会福利和价值逐渐提高，进城农民的社会保险、子女入学等权益逐渐得到保障。2014 年《国务院关于进一步做好为农民工服务工作的意见》提出，稳定就业关系的用人单位应将农民工纳入城镇职工基本养老保险和基本医疗保险，灵活就业的农民工也可以参加当地城镇居民基本医疗保险。2016 年开始实施的《居住证暂行条例》，为进城农民在城市享有基本社会服务提供了制度保障。上述一系列政策意味着“农业转移人口与城镇户籍居民在职工社会保险准入上没有根本的差别”。①

其二，试图通过进城农民户籍的城镇化来实现扩大内需及稳定房地产市场等经济任务，理论上确有可能但实践作用甚微。在城镇落户政策基本放开的背景下，进城农民往往并不需要以购买房屋的条件获得城镇户籍。各地购房政策除了人才引进特殊房之外，购房资格已经不以户籍为限制条件，购房能力也并不会因户籍转化而提高。故试图以进城农民户籍的转化来扩大内需、稳定房地产市场的路径可行性较低。

（三）户籍人口城镇化率是一个结果而非目标

户籍人口城镇化率是新型城镇化建设的一个结果而非目标。顶层设计将户籍人口城镇化率作为衡量中国城镇化建设健康与否的关键指标和规划任务。理论研究以此为导向，积极构建城镇常住人口转变为户籍人口的理论支撑。毋庸置疑，城镇化进程会带来常住人口和户籍人口城镇化率的提高，但城镇化的目标并非简单的户籍人口城镇化率指标，而是以人为中心，旨在促进和保障常住人口和进城农民平等享有公共服务。故不能本末倒置，误将可能的结果作为城镇化进程的目标，否则既误导了地方实践和理论研究导向，最终也难以实现目标。

三　保留进城落户农民土地承包经营权是新型城镇化的另一种路径可能

不管进城落户农民土地承包经营权是退出还是保留均会产生相关主体的利益冲突，关键是如何平衡这些冲突，如果保留相较于退回产生的冲突更小，带来的制度效益更好或者更为公平，则应该保留。保留进城落户农民的集体“三权”不应成为退出承包地机制中的权宜之计，在转变户籍决定论的城镇化发展理念的情况下，进城落户农民土地承包经营权的保留更具有独立的价值。

其一，转变户籍决定论的城镇化发展理念，将户籍和财产权及成员权解绑是构建新型城镇化和农民财产权利理论的基础。农民户籍身份的捆绑，使得农民“既无力改

① 田明、李辰、赖德胜：《户籍制度改革与农业转移人口落户——悖论及解释》，《人口与经济》2019 年第 6 期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

变自我身份，也难以自由处分权利，最终成为‘内部人’、‘单向度’的人”，[①] 不利于城乡的互动和融合。现有法律对集体成员权采取了模糊或有意模糊的安排，地方政府往往以便捷简易的户口为基础，并将其作为农村集体成员权认定的基础原则，但实践中集体成员权的边界范围并非严格按照户籍认定，是“可以根据集体行动、社区条件灵活变动的”。户籍这一相对固化的行政登记制度不应成为集体成员权这一私权得丧变更的条件，也和实践中如外来户、迁出户、外出务工读书等仍然享有集体经济组织成员的事实存在偏差。

其二，农民在农村享有的土地承包经营权本是属于农民法定的财产权利，不能仅仅由于权利主体的户籍和地域的变更而丧失。法律明确了农民对土地承包经营权享有的法定物权类型。土地承包经营权虽然是农民基于成员身份而享有的分配权利，但成员权仅仅是分配取得的必要条件，不是其取得或丧失的充分条件。因为即便享有成员权也不一定获得承包权，还需要发包方和承包方遵循法定的原则和程序签订土地承包合同，方能设立土地承包经营权这一用益物权。

其三，在城乡二元制度下，农民实质上是被排除在国家的社会保障系统之外的，“国家因为客观原因没有为农村居民提供完善的社会保障制度”。[②] 其享有的承包地本质上是供其自给自足的生活和生产来源，如往前追溯至农村合作化、集体化运动之前，甚至可以说土地承包经营权所依附的土地都是属于农民自己的财产。此外，进城落户的农户，除了因土地征收成为城镇保障居民外，均是通过自身的劳动和努力在城市扎根落户，其享有的城镇保障本质上是通过征地补偿和自我付出而获得的。因此，进城落户农民继续保留土地承包经营权并不存在所谓的城乡不公平之嫌。

其四，保留进城落户农民承包地，承包权的固定并不会导致农村新增人口的保障丧失。承包地的具体权利行使和分配主体均为户而非个人。承包地的固定更多是对外关系的固定，即对集体而言的权利固化，并不会影响户内人口增减带来的成员内部关系，新增人口或减少人口可基于婚姻家庭继承制度解决财产处置和保障问题，绝户的情形直接基于主体的消亡而丧失权利，由集体承继财产。此外，保留进城落户农民的承包地可能带来农地闲置或影响土地集中处置等问题，但这些问题可通过加强管理予以解决，如规定不得闲置，如闲置满多少期限的，村集体经济组织有权强制流转等规则的完善予以解决。

其五，中国的新型城镇化应转变唯户籍论的观念，在此观念转变下厘清和改革将

① 刘云生：《从“城乡区隔”迈向“开放社会”》，载刘云生主编《中国不动产法研究》（总第20辑），社会科学文献出版社，2019，第317页。

② 程雪阳：《重建财产权：我国土地制度改革的基本经验与方向》，《学术月刊》2020年第4期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

户籍与成员权绝对捆绑、成员权和财产权不分等理论误区。只有将农民享有的土地承包经营权作为一项真正的用益物权，才能解释进城落户农民土地承包经营权为何可以保留的法理问题。只有将进城落户农民土地承包经营权的保留独立于退出机制予以解读，才能探索出新型城乡关系所需的新制度路径。故进城落户农民土地承包经营权的保留具有合理合法性，并无双重保障的不公平嫌疑。城镇化的最佳策略也不是农村向城市的单向转变，而应是城市和农村“双向发力”，实现城乡资源合理配置的均等化发展目标，彼时的“上山下乡”则可能会“成为时代发展、城乡共荣的显著表征”。①

An Interpretation of Land System in *The Civil Code*

Zuo Chuanwei, Song Zongyu, Chen Jiebin, Song Zhihong, Huang Zhong, Shan Pingji, Jiang Hongli

Professor Liu Yunsheng:

The Civil Code was officially implemented on January 1, 2021, and became an important turning point in the study of our national law from legislative theory to interpretation. In the process of codification, *The Civil Code* absorbed and solidified the results of a new round of land system reform, and the main task at present is to interpret the land system in *The Civil Code* and to make a rational analysis of the understanding and application of relevant provisions. To this end, this collection organized “*The Civil Code* in the interpretation of the land system” written talk, a total of 7 experts 6 essays to participate in this written talk.

In the article “On the Predicament and Possible Solutions of ‘Three Rights Separation’ of Homestead Land”, ZUO Chuanwei argues that, due to the narrow trading space of the rural homestead use right, the “three rights separation” of homestead land has not occurred in the vast rural areas. Corresponding policy effects, in order to revitalize the idle homesteads and farmhouses, it is necessary to analyze the special reasons for the narrow trading space and seek targeted solutions. Under the premise of adhering to the public ownership of collective land, we can expand the connotation of the right of residence in *The Civil Code* and use the right of consumption and investment to inhabit the housing base and farmhouse.

In the article “the Legal Difficulties and Countermeasures Analysis of the Income

① 刘云生：《农地股份制改革：双向目标定位与民间法权表达》，《东方法学》2018年第5期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Distribution of Collective Construction Land Entering the Market", SONG Zongyu and CHEN Jiebin argues that there are some problems in the distribution of income from the collective operation construction land entering the market, such as lack of upper law, unclear legal nature of adjustment fund, and unclear rules of income distribution within the collective. We should steadily establish the tax system of collective land value added income, clarify the government functions through legislation, and reserve the legal space to connect with other systems.

In the article "the Collective Construction Land Use Right from the Perspective of *The Civil Code*", SONG Zhihong claims that chapter 12 "the Construction Land Use Right" in the real right section of *The Civil Code* does not provide a direct institutional basis for the operation rules of the construction land use right. Article 63 of the Land Administration Law on the subject and mode of the establishment of collective construction land use right should be understood, supplemented and improved in combination with *The Civil Code*.

HUANG Zhong argues in "Three Questions on the Interpretation of the Classification of Usufructuary Rights in *The Civil Code*" that, based on the systematic interpretation, the usufructuary right holder is not necessarily entitled to independent expropriation and compensation. Based on the historical interpretation, the registration of change in *The Civil Code* is a concept with dual connotations, including "transfer registration" and "registration of change". Based on purpose (function) interpretation, easement and residence right can guide the reform practice of land piao (land index) transaction and "three rights separation" of homestead.

In "Several Issues Concerning the Application of Land System in *The Civil Code*", SHAN Pingji believes that after the expiration of the right to use residential construction land, how to renew the right to use residential construction land, the payment or reduction of the renewal fee and other issues still need to be further clarified by legislation. The land contracted management right can be used as the object of financing guarantee, and is no longer limited to the "wasteland" contracted management right to set mortgage, which is worthy of affirmation. From the perspective of functionalism, the form of financing guarantee of land management right can not only take mortgage, but also be interpreted as the pledge of rights that can be set.

In the article "Several Issues Concerning the Application of Land System in *The Civil Code*", Jiang Hongli believes that the new urbanization road should gradually change the

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

urbanization concept of household registration determinism, which is the system background of correctly interpreting the system background that farmers who settle down in cities can retain the land contract and management right. It is legitimate and reasonable to construct a land contract management right retention system for rural residents independent of the withdrawal mechanism, which is an institutional exploration for the interaction and integration of urban and rural areas.

Keywords: *The Civil Code*; The Collective Operation Construction Land; Right of Residence; Land Management Rights; Rural Homestead Use Right

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net